

1502681-78.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502681-78.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502681-78.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284553/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 20895814 - 04º D.P. GUARULHOS, 5136/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2284553 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIO ALVES DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

IGOR GOMES DA CONCEIÇÃO e VINICIO ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 22h20min, na Rua Wambes, 100, Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas, traziam consigo, para fins de tráfico, 61 porções de maconha, com massa líquida de 79,68 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 19 e laudo de fls. 30/32) (fls. 69/70).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/35).

Devidamente notificados (réu Igor - fls. 147/148 e réu Vinício - fl. 119 e fl.

149), os acusados ofereceram defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (réu Igor - fls. 157/158 e réu Vinício - fls. 72/99).

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (fls. 165/168).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 28 de abril de 2022, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns, Wildson Novais de Souza (PM) e Jorge Luiz da Conceição Júnior (PM) e das testemunhas arroladas pela defesa de Vinício, Matheus Henrique da Silva Almeida, Luiz Eduardo Oliveira de Sá e Evellyn Francisca Linhares. A defesa desistiu dos depoimentos de André Wilha Torres Barbosa, José Marinho Mendonça Oliveira e Sérgio José da Silva, o que foi homologado. Em seguida, os réus foram interrogados. Na oportunidade, foi determinado para oficiar à Escola Estadual Maria Leda requisitando eventuais filmagens gravadas do dia/horário dos fatos. Ainda assim, considerando que restaram fragilizados os indícios de autoria com relação ao réu Vinício, foi revogada a prisão preventiva decretada (fls. 224/226).

Foram acostados aos autos B.O/P.M. e ofício da escola E.E. Professora Maria Leda Fernandes Brigo (fls. 279/285 e fl. 290, respectivamente).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em memoriais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu que a ação penal seja julgada parcialmente procedente, com a condenação de IGOR e absolvição de VINICIO. A respeito do cálculo da pena, o réu IGOR é reincidente específico. Não é possível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. O regime inicial deverá ser fechado, devido à natureza equiparada a hediondo do crime. Pela mesma razão, inviável a aplicação de penas alternativas (fls. 317/320). A defesa de VINICIO ALVES DE OLIVEIRA reiterou o pedido do parquet para que seja o réu absolvido, nos termos do artigo 386, incisos IV e VI, do CPP. Na remota hipótese de condenação, postulou seja aplicado a pena no mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal; seja realizada a detração penal; aplicado o regime aberto para o início de cumprimento de pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, do Código Penal. Por fim, pleiteou a concessão do direito de apelar em liberdade com a imposição das medidas cautelares, sendo fielmente cumprida pelo réu sob pena de revogação (fls. 328/345).

Por fim, a defesa de IGOR GOMES DA CONCEIÇÃO requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do denunciado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, seja afastado o tráfico de drogas; seja observada a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, inclusive com a possibilidade de conversão em restritiva de direitos; seja aplicado o artigo 44 do Código Penal; seja aplicada a atenuante da menoridade; seja observada todas as circunstâncias favoráveis ao réu, fixando a pena no mínimo legal; seja afastada a pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência do acusado. Por fim, postulo que o denunciado possa apelar em liberdade, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício (fls. 347/367).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01 e fl. 10), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição/apreensão (fl. 19), laudo de constatação provisória (fls. 30/32), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de Tetrahydrocannabinol-THC, bem como pela prova oral trazida aos autos.

Já no que pertine à autoria, esta também é segura com relação ao acusado IGOR. O mesmo, no entanto, não se pode falar com relação ao corréu VINICIO, senão, vejamos. Os acusados IGOR GOMES DA CONCEIÇÃO e VINICIO ALVES DE OLIVEIRA, em sede policial, permaneceram em silêncio (fls. 11/12).

O acusado IGOR GOMES DA CONCEIÇÃO, em juízo, permaneceu em silêncio.

O acusado VINICIO ALVES DE OLIVEIRA, em juízo, negou os fatos. Afirmou que foi na praça na companhia de sua namorada Evellyn para entregar um cachecol para Igor. Ficaram no banco debaixo esperando Igor por cerca de quinze a vinte minutos, quando Igor chegou, pegou o cachecol e saiu. Minutos depois veio a polícia. Foram

revistados e nada encontrado. O policial lhe mandou ir embora, mas antes informou que tinha passagem e tudo mudou. Foi levado até a viatura e lá encontrou Igor detido e chorando. Foram agredidos, inclusive, quebraram o dente do Igor. A partir desse momento, cessaram as agressões. Não viu os policiais encontrando as drogas. Não tinha problemas com os policiais.

Os policiais militares WILDSO N NOVAIS DE SOUZA e JORGE LUIZ DA CONCEICAO JUNIOR, em sede inquisitorial, em depoimentos semelhantes, narraram que patrulhavam pelo bairro de Jd. Cumbica, quando por volta das 22:20 horas passavam pela Rua Wambes, altura do numeral 1000, avistaram dois indivíduos, os quais saíram correndo, que perseguido foram abordados e revistado, que o indivíduo identificado como Igor Gomes da Conceição, portava no bolso da blusa um saco plástico contendo 61 invólucros de erva, semelhante a maconha, que o segundo indivíduos identificado como Vinício Alves de Oliveira, confessou que era o gerente da "boca". Que ambos os indivíduos são reincidentes no crime de tráfico. Vinício foi preso há exatamente quatro meses (fls. 20/21).

Em juízo, o policial militar WILDSO N NOVAIS DE SOUZA narrou que estavam em patrulhamento quando abordaram dois indivíduos em uma praça, na frente de uma escola. A escola estava em funcionamento, próximo ao horário de saída de alunos. A praça era conhecida como ponto de tráfico de drogas. Na ocasião, havia outras pessoas no local, comprando drogas. Todos correram. Foi em direção àquele que estava, aparentemente, vendendo drogas. Abordado, com ele, nas vestimentas, foi encontrada uma sacola, onde estavam as drogas. Não se recorda se havia dinheiro. Ele confessou o tráfico. Outra pessoa foi abordada também por seu parceiro. Ele teria dito que estava na campana, vistoriando para verificar a presença de viaturas. Havia uma moça na praça e essa disse que conhecia um dos abordados. Em audiência, reconheceu Igor como a pessoa que abordou na ocasião.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar JORGE LUIZ DA CONCEICAO JUNIOR, o qual, em juízo, não reconheceu os acusados, em razão do tempo decorrido. Narrou que estavam em patrulhamento e que, ao chegarem em uma rua, viram os dois indivíduos, sendo que cada um saiu para um lado. Como a praça era ponto de tráfico, resolveram abordá-los. O rapaz abordado pelo depoente ainda tentou correr. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Seu parceiro abordou o outro, com quem foram encontradas drogas. Ambos negaram a traficância. Tem uma escola perto da praça e não estava funcionando por conta da pandemia. Na praça, ainda, tinha uma menina, que disse que um fornecia as drogas para o outro vender. Não se recorda se essa moça foi qualificada ou levada na delegacia. Era o condutor da viatura. Seu parceiro desembarcou e o depoente deu a volta com a viatura e realizou a abordagem. Em audiência, apontou Igor como sendo a pessoa que teria abordado na ocasião, mas não tinha mais certeza. Indagado pela defesa, não viu seu parceiro localizando as drogas, mas pelo que soube, estavam no bolso da calça/bermuda do indivíduo. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM

PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

A testemunha arrolada pela defesa do réu Vinício, EVELLYN FRANCISCA LINHARES, em juízo, namorada de Vinício, afirmou que estava com ele na data dos fatos na praça. Igor estava com Mateus e Luiz Eduardo. Igor foi até o encontro do casal, pegou o cachecol e saiu andando. Cerca de cinco minutos uma viatura passou. Um dos policiais abordou Vinício e ele informou que entregou o cachecol para Igor. Foi revistado e nada foi encontrado. Igor saiu da praça quando a polícia passou, vindo a ser abordado um pouco distante, não tendo presenciado tal abordagem. Não soube dizer se foram encontradas drogas com Igor. Quando ele retornou à praça, já estava detido na viatura. No dia dos fatos, estava tendo aula na escola que fica na frente da praça. Informou que o local não é mais ponto de drogas. Negou ter dito aos policiais que os acusados eram traficantes.

A testemunha arrolada pela defesa do réu Vinício, LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE SÁ, em juízo, disse que conhece os acusados do bairro. Presenciou a abordagem do Vinício e Igor só o visualizou na viatura. Declarou que estavam assistindo um jogo do "Flamengo" no celular, por volta das 21h. Passou a viatura e Igor saiu do local, tendo dito que ia comprar um leite para a filha e que estava "assinando", portanto, não poderia ficar na rua. Igor desceu, pegou o cachecol com Vinício e Evellyn e saiu andando. Não chegou a vê-lo sendo abordado. Quando a viatura voltou, Igor já estava detido. No dia dos fatos, estava tendo aula na escola que é na frente da praça. Não há mais ponto de tráfico de drogas no local. Informou, ainda, que antes da abordagem estava com Igor e não viu sacola com ele.

A testemunha de defesa do réu Vinício, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, em juízo, disse que conhece os acusados e presenciou a abordagem de Vinício. Narrou que estavam sentados na praça assistindo ao jogo do time "Flamengo" no celular com Igor e outros. Vinício e a Evellyn estavam na parte debaixo da praça. Quando a viatura passou, Igor foi embora porque estava assinando e precisava comprar leite para filha dele. Igor desceu, pegou o cachecol com o Vinício e saiu andando. O policial que estava a pé abordou Vinício e a Evellyn. Visualizou Vinício ser revistado e nada foi encontrado. Após alguns minutos, a viatura retornou com Igor já detido. Antigamente, a praça era ponto de drogas, mas por ser um local aberto e próximo de escola, não era estrategicamente bom. Informou, ainda, que antes da abordagem estava com Igor e ele não tinha sacola.

Pois bem, diante dos depoimentos seguros dos policiais militares, ouvidos na fase policial e em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que IGOR trazia consigo, para fins de tráfico, os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Ressalte-se que ambos os policiais foram enfáticos quanto a localização das drogas com apenas um dos agentes abordados, sendo que as testemunhas de defesa não desmentiram tais declarações, até porque nenhuma delas presenciou a abordagem do acusado IGOR. Aliás, declararam que só visualizaram a abordagem do réu Vinício e nada com ele foi apreendido.

O fato das testemunhas terem dito que estava com Igor momentos antes da abordagem e que não viram com ele nenhuma sacola com drogas, não retira a credibilidade dos depoimentos das testemunhas policiais, pois, conforme narrado pelos policiais, tanto em juízo como na fase policial, a sacola estava no bolso da blusa, portanto, não aparente, daí porque o fato das testemunhas não terem visto o acusado com referida sacola não quer dizer que ela não estava na posse dele.

Nesse ponto é bom destacar que eventuais contradições pontuais entre os depoimentos dos policiais, em pontos circunstâncias, não retira fragiliza tais depoimentos, mas, pelo contrário, lhe conferem maior credibilidade, tendo em vista que o decurso do tempo e a participação em diversas ocorrências parecidas faz com que seja natural eventuais confusões quanto a detalhes das diversas ocorrências. Por outro lado, em juízo, o réu IGOR permaneceu em silêncio, não contrapondo a narrativa dos policiais.

Assim, considerando que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, é de se reconhecer que a prova é segura n sentido de que o acusado portava a sacola com drogas, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado IGOR com os entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade de drogas apreendidas (61 porções de maconha, com massa líquida de 79,68 gramas), incompatível com a posse para uso, da forma como estavam embaladas e separadas, bem como das circunstâncias que envolveram a prisão.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p. 8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: "considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Já quanto ao corréu VINÍCIO, como bem pontuado pelo representante ministerial, outra é a solução.

Ao término da instrução criminal, sopesando as provas colhidas, verifica-se que não há elementos suficientes a autorizar o juízo seguro, acima de qualquer dúvida razoável, necessário à edição de um édito condenatório na esfera criminal.

A condenação criminal pela prática de qualquer delito, até mesmo uma simples contravenção penal, somente se justifica quando existente no processo elementos de convicção que, projetando-se além de qualquer dúvida razoável, confirmam certeza absoluta ao decreto condenatório, o que não foi produzido nesses autos.

Isto porque após a instrução, não foi possível vincular o réu de forma irremediável à conduta criminosa descrita na denúncia.

Como já delineado acima, conforme evidenciado na instrução criminal, não foi apreendido qualquer entorpecente em seu poder.

Ademais, VINÍCIO negou veementemente a participação na traficância e as testemunhas de defesa confirmaram o seu não envolvimento com o tráfico, declarando que visualizaram a abordagem do réu e nada com ele foi localizado e apreendido pelos policiais.

Além do mais, não há elementos que indiquem, de forma segura e clara, a participação e/ou colaboração do citado denunciado com a conduta do corréu Igor. É sabido que, para a decretação de uma sentença condenatória, o juízo deve ter plena convicção a respeito da materialidade e autoria delitiva, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, ante da dúvida quanto à autoria delitiva, a absolvição do réu VINÍCIO é medida de rigor, pois no processo penal, a dúvida deve beneficiar as Defesas aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência:

"Diante da fragilidade da prova de efetivo envolvimento do acusado no crime em questão, é o caso de incidência dos brocardos in dubio pro reo e favor rei somente restando proclamar a improcedência da pretensão ministerial" (STF, AP n. 678, Min. Dias Toffoli, j. 18.11.2014);

"Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática". Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136);

"Se o espírito do magistrado é animado pela incerteza, forçoso convir que outro caminho ele não terá, senão o da absolvição, pois é máxima de processo penal que a dúvida, sentimento alternativo que inclui o sim e o não, sempre deve prevalecer em benefício do réu" (TACRIM 11 C AP 10811421/2 J. 9.2.98 Rel Xavier de Aquino Rolo-flash 1.155/060);

"Prova - Elementos insuficientes para configuração do crime. Absolvição - Necessidade. A dúvida, quanto à configuração do crime por insuficiência probatória, deve ser resolvida em proveito do réu com a absolvição" (TACRIM 11 C. AP 787773 J. 22.8.94 Rel. Fernandes de Oliveira Rolo-flash 857/208).

No mesmo sentido, ensina Heleno Cláudio Fragoso:

"Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta sequer, a alta probabilidade, que é apenas

um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade” (Fragoso, Heleno Cláudio. Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, p. 506).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação apenas do acusado IGOR, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, verifico que o acusado cometeu o delito nas condições normais previstas no tipo penal, razão pela fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Observo que a quantidade de entorpecente apreendida não se mostra excessiva a justificar o aumento da pena-base (61 porções de maconha, com massa líquida de 79,68 gramas). Na segunda fase da pena, presente a atenuante da menoridade relativa. Presente, também, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 1500413-51.2021.8.26.0535, da 5ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena nº 0018919-15.2021.8.26.0224, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 39/40 e F.A. de fls. 44/45 e fls. 203/205), sendo, portanto, reincidente específico. Assim, compenso a atenuante com a agravante e mantenho a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual torno as penas definitivas em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Observo que, em face da reincidência específica, fica afastada a causa de diminuição de pena tipificada no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Não há que se falar em bis in idem mormente porque, para incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o réu seja primário, o que não se verifica no caso em análise.

Esse é o forte posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE DOIS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU À INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES QUE NÃO ENSEJA BIS IN IDEM. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO MONTANTE DA REPRIMENDA IMPOSTA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A reincidência do paciente constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de

diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Precedentes. - Ademais, a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 630.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (Grifei);

“(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido”. (STJ HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Diante da quantidade da pena imposta e reincidência do agente incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena é o FECHADO para o acusado IGOR, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostraram adequados para a ressocialização do réu, além do fato de ser reincidente específico, demonstrando dedicação à prática delitiva, evidenciando que faz do crime um meio de vida e que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito a seguinte jurisprudência:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu IGOR, o fato do acusado ser reincidente específico, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das

condições subjetivas e a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

I - CONDENAR IGOR GOMES DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

II - ABSOLVER VINICIO ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação que lhe move a Justiça Pública, por infração prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu IGOR não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno o réu IGOR ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.

No mais, indefiro o pedido de isenção de dias-multa pleiteado pela defesa de Igor, pois trata-se de pena prevista de forma cogente e cumulativa no preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou suspensão de tal multa, sob pena de ferir-se o princípio da Reserva Legal.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu Igor, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;

2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu Igor.

P.I.C.

Guarulhos, 22 de setembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA